

【法官后语】

本案原审被告人孙某某盗窃三次，作案四起，盗窃物品中可以确定的数额为8901元，达到数额较大的标准，同时也符合盗窃多次的入罪标准。本案的争议焦点就在于对孙某某罚金刑的判处应如何适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定，是否属于“没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算”的情况，原判对原审被告人孙某某的罚金刑判处是否适当。

第一种观点认为，本案鉴定已确认的孙某某的盗窃数额为8901元，不属于没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的情形，应当在1000元至17802元之间对其判处罚金，原判对其判处的罚金数额超过盗窃数额二倍，属于适用法律错误，这也是检察院提出的抗诉理由。第二种观点认为，孙某某能够认定的盗窃数额虽然仅为8901元，但还有部分被盗物品并未作价，且从销赃数额来看远超可以确定的盗窃数额，从总体上属于“没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算”的情形，应当对其在1000元以上10万元以下判处罚金。笔者同意后者的观点，有以下三点理由。

第一，本案从总体上看属于“没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算”的情形。对于盗窃数额，认定的一般方法是按照有效价格证明或价格认证确定。本案被告人孙某某砸车盗窃3次，作案4起，其中能够作价的部分分别为2998元、3510元、2393元，共计8901元，另有一起被盗物品全部未作价，但可以确定部分销赃数额为10800元，还有一起被盗物品仅部分作价。现行司法解释已经取消1998年《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（已失效）中关于“销赃数额高于按解释计算的盗窃数额的，盗窃数额按销赃数额计算”的规定，因此我们不能直接将销赃数额计算为盗窃数额，但可以将其纳入犯罪事实中考虑。既然原判在事实认定中客观描述了盗窃的财物，同时部分被盗物品由于客观原因没能鉴定作价，且未作价的部分中可以确认的销赃数额（10800元）高于当前已作价的数额（8901元），笔者认为，从总体上按照司法解释中盗窃数额无法计算的情况来适用更为恰当合适，符合本案的具体情况。

第二，适用“没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算”的情形符合罪责刑相适应的原则。《中华人民共和国刑法》第五十二条规定，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。因此，在判处罚金刑的时候，应从犯罪数额、违法所得、损失大小、主观恶性、犯罪手段等方面综合考虑。本案被告人孙某某采用破坏性手段实施盗窃活动，犯罪手段恶劣，造成车辆损失共计5890元，按照现行司法解释的规定，应当从重处罚，不仅应在自由刑上从重处罚，在罚金刑方面亦应从重处罚。从违法所得来看，本案第一起盗窃事实中6瓶飞天茅台酒销赃数额为10800元，受害人柳某报案时陈述价格为18966元，且从社会常理来看，销赃数额一般小于盗窃物品实际价值，倘若将该销赃数额计入犯罪数额，判处罚金3万元仍在犯罪数额的二倍以下。综合考虑本案犯罪数额、违法所得、造成损失大小等犯罪情节，对孙某某判处罚金数额适用“没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算”的情形，不受盗窃数额的限制，对其处以更重的罚金，与孙某某的犯罪情节更相适应，符合罪责刑相适应的原则。

第三，本案同时符合盗窃数额较大和多次盗窃，但以多次盗窃入罪更为合理。1979年《中华人民共和国刑法》对盗窃罪仅规定了“盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额较大的”一种情形，随着经济社会和司法实践的不断发展变化，1997年《中华人民共和国刑法》增加了“多次盗窃”情形，2011年《中华人民共和国刑法修正案(八)》又增加了“入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的”等情节入罪的情形，由此盗窃犯罪形成了以数额入罪的数额犯和以上述几种情形入罪的非数额犯。相应地，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条也对盗窃罪罚金刑的判处进行了调整，分别适应数额型和非数额型两种情形。实践中，盗窃行为既可以数额入罪，又可以情节入罪时，若因部分被盗物品无法作出价格鉴定等原因，导致能够认定的盗窃数额明显低于实际盗窃物品价值的情况，如前所述，应对其适用“没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算”的情形，若认定其盗窃数额较大则与此相矛盾。因此，本案以多次盗窃入罪，盗窃数额作为犯罪情节更为适宜。

编写人：北京市第三中级人民法院 钟欣 编辑

利用公司的直播账号向自己私人账号打赏行为的定性

——穆某盗窃罪

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省盐城市亭湖区人民法院(2022)苏0902刑初493号刑事判决书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

2021年1月，被告人穆某入职江苏某文化传媒有限公司运营部，担任直播运营一职，负责管理主播直播状态、剪辑和发布短视频。2022年1月13日至5月23日，被告人穆某秘密登录江苏某文化传媒有限公司多个短视频平台账号，通过直播打赏的方式，秘密转移该公司819958个某平台币(价值人民币81995.8元)到其控制的账号，并实际提现人民币33694.05元，另有15600个某平台币(价值人民币1560元)未提现。

被告人穆某被抓获归案后如实供述了上述事实。在本案侦查及审理期间被告人穆某已向公安机关退出全部赃款人民币81995.8元，该款已由公安机关全部发还被害单位。

【案件焦点】

1. 行为人偷偷登录公司的直播账号，向自己账户打赏后提现获利的行为应如何定性；2. 如何认定犯罪既遂的时间节点。

【法院裁判要旨】

江苏省盐城市亭湖区人民法院经审理认为：被告人穆某以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取公私财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人穆某归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。案发后被告人穆某退出全部赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人穆某的犯罪情节和悔罪表现，可给予其一定考验期限宣告缓刑。据此，判决如下：

被告人穆某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币35000元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

2009年《中华人民共和国刑法修正案(七)》颁布实施以来，非法获取计算机系统数据罪得以确立并实施。该罪的应用，对于完善我国刑法体系，保护公民法人的计算机信息系统数据，打击利用计算机实施犯罪行为的发生起到了较好的效果。但在司法实践中，该罪的认定存在诸多争议，其中争议最多当属该罪与盗窃罪区分的问题。对于如何惩治非法获取虚拟财产行为，各地法院裁判不一，不符合刑法制度的确定性原则，同时，也增大了司法审判工作的难度。

一、实践冲突：盗窃罪与非法获取计算机信息系统数据罪定罪分歧

以虚拟财产为对象的犯罪，是以非法获取计算机信息系统数据罪还是以盗窃罪处理，司法实践中均存在较大争议。一种观点认为，该类犯罪应以非法获取计算机信息系统数据罪论处；另一种观点认为，该类犯罪应以盗窃罪论处。

笔者认为，对于此类犯罪的定性不能一概而论。首先，虚拟财产具有管理可能性、转移可能性和使用价值，难以回避其财产属性，如果对该类犯罪不能以财产犯罪论处，在行为人通过暴力或者骗取等手段骗取虚拟财产的情况下，可能只能认定为侵犯人身的犯罪甚至是无罪，因为非法获取计算机系统数据罪

要求行为人必须以非法手段获取，如果不是技术手段，则难以认定该罪，这种结果显然令人难以接受。其次，虽然虚拟财产具有财产属性，但其与普通的财产依然存在很大的区别，突出表现为部分虚拟财产的价值缺乏普遍认可、相对客观的衡量标准。一方面，对于虚拟财产的持有者而言，它可能具有很大的价值，但是在部分不参与相关网络活动的人的眼中可能一文不值；另一方面，当前网络市场竞争激烈，一些游戏或者应用刚开始上市时可能炙手可热，虚拟财产的价格也水涨船高，但可能几年甚至短短几个月就被新的游戏或者应用替代，原有的用户也会将游戏或应用包括里面的虚拟财产置之—隅，即使想要将自己的虚拟财产连同账号打包出售，往往也要大打折扣，此时网络运营商出售的价格便不能反映虚拟财产的真实价格。综合以上，对于虚拟财产犯罪，要结合案件的具体情况综合认定行为人的行为性质，在无法认定行为人的行为构成计算机犯罪的情况下，如果可以确定虚拟财产的价值，则可以按照财产犯罪论处。

二、个案分析：本案认定为盗窃罪的观点阐释

（一）行为人偷偷登录公司的直播账号，向自己账户打赏后提现获利的行为的定性

本案不应以非法获取计算机系统数据罪论处。非法获取计算机系统数据罪，是指采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，情节严重的行为。被告人穆某系公司运营部的工作人员，其在工作过程中接触到了公司的某平台账号，随后其在自己手机上偷偷登录公司的直播账号，并对自己的账号进行打赏，并未采取技术手段。并且非法获取计算机系统数据罪属于妨害社会公共管理秩序的犯罪，侵犯的是社会公共法益，而本案中被害人只有虚拟财产的所有人直播公司，并不涉及社会公共法益的侵害。

本案不宜以职务侵占罪论处。职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为，包括利用职务上的便利窃取、骗取、侵占本单位财物的行为以及其他将本单位财物占为己有的行为。行为人必须利用了职务上的便利，即利用自己主管、管理、经营、经手单位财物的便利条件。但这里的“管理”“经营”“经手”并

不是指普通意义上的经手，应是指对单位财产的支配与控制；或者说，利用职务上的便利是指利用本人职务上所具有的自我决定或者处置单位财物的权力、职权，而不是利用工作机会。被告人穆某系公司运营部工作人员，工作职责：一是转发主播的短视频；二是在直播掉线的情况下，帮助主播重新登录，其在工作中可以接触到公司的某平台账号，但是公司的某平台账号只能在公司的工作手机上登录，不可以在个人手机上登录。公司还有推广部，推广部负责使用公司事先充值好的某平台币按照公司要求打赏到指定的某平台账号。因此穆某利用的只是工作便利，而非职务便利，其行为不宜认定为职务侵占罪。

本案应以盗窃罪论处。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条的规定：“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。”换言之，即使行为人利用计算机实施犯罪，但只要其行为符合盗窃罪的构成要件，也应以盗窃罪论处。盗窃罪是指以非法占有为目的，窃取他人占有的数额较大的财物，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。

盗窃的对象应为刑法意义上的“财物”，某平台币能否认定为“财物”？首先，某平台币具有管理的可能性，一个人一旦注册了某平台账户成为某平台用户，就可以充值某平台币，形成对某平台币的管理和控制；其次，某平台币具有转移可能性，某平台币是由某平台公司发行，某平台用户通过人民币按照一比一的比例购买，以电磁记录的方式存储于某平台服务器内，并以特定数字单位表现的虚拟兑换工具，用户可以通过某平台币购买礼物赠与主播，主播也可以通过提现将某平台币转换为法定货币；再次，某平台币具有使用价值，其可以用于购买礼物、提升用户等级，可以满足用户的精神需求；最后，从案发前到判决宣告时，某平台APP均保持着数以亿计的平均日活跃用户，某平台币也依然保持着与人民币一比一的固定兑换比率，将某平台币认定为“财物”，符合一般民众的认知，其财产价值也可以确定。因此，某平台币可以认定为“财物”。

盗窃罪的行为是窃取他人占有的财物，窃取是指违反被害人的一致，将他

